

יסודות חוקתיים

נורמות, נוהגים וכללים שאינם מעוגנים בחוקה פורמאלית אך קובעים את האופי הדמוקרטי והלאומי של המדינה, ומנחים את רשויות השלטון בעבודתן. בהעדר חוקה בישראל מהווים הכרזת העצמאות, חוקי היסוד וחוק השבות וחוק האזרחות את היסודות החוקתיים של המדינה.

החלטת הררי

הידועה גם כ**פשרת הררי**, היא החלטה של **הכנסת הראשונה** אותה יזם **חבר הכנסת יזהר הררי** מן המפלגה הפרוגרסיבית. ההחלטה, שהתקבלה ביום 13 ביוני 1950, קובעת כי הכנסת הראשונה לא תחוקק **חוקה** למדינת ישראל, וכי החוקה תיכתב בפרקים, הקרויים "**חוקי יסוד**", שיאוגדו, לבסוף, לכלל חוקת המדינה. כתוצאה מהחלטה זו, אין למדינת ישראל חוקה כתובה, ושטחים ונושאים רבים וחשובים אינם מוסדרים בחוקה.

חוקי היסוד ומעמדם

חוקי היסוד שונים מחוקים רגילים:

מבחינת הצורה: בחוקי יסוד לא מצוינת שנת החקיקה. והחוק מנוסח בכלליות ובאופן עקרוני בלבד.

מבחינת התוכן: חוקי יסוד עוסקים בעניינים שבהם עוסקת חוקה, כמו הגדרת אופייה ודמותה של המדינה, תפקידיהם וסמכויותיהם של רשויות השלטון, הגדרת מבנה המשטר והבטחת זכויות האדם והאזרח.

מבחינת מעמד: לחלק מחוקי היסוד בדומה לחוקה יש מעמד על שמתבטא ב:

א. **שריון סעיפים בחוק:** ניתן לשנות חוק יסוד רק ברוב מוחלט (מעל 60 חברי כנסת).

ב. **פסקת הגבלה:** מונעת מהרשות המחוקקת לחוקק חוק הסותר את תוכנו של חוק יסוד, אלא אם התקיימו שלושה תנאים- החוק הולם את ערכיה של מדינת ישראל, נחקק לתכלית ראויה, ופגיעתו בעקרונות חוק היסוד היא במידה שאינה עולה על הנדרש.

ג. **יציבות:** לא ניתן לשינוי בתקנות לשעת חירום.

שריון סעיפי החוק מגן על מעמדו הפורמלי ואילו פסקת ההגבלה מגינה על מעמדו במובן המהותי, מכיוון שהיא עוסקת בהגנה על עקרונות החוק בהתאם לפרשנות שתינתן להם על ידי הרשות המחוקקת ועל ידי הרשות השופטת שמבקרת את החוק.

ההבדלים בין חוק יסוד לחוק רגיל

בצורה: בחוקים רגילים מציינים בכותרת את שנת החקיקה ואילו בחוקי יסוד לא מציינים את השנה. הדבר מעניק לחוק יסוד מעמד על של חוק שאינו מוגבל בזמן.

חוקי יסוד כתובים בלשון קצרה ותמציתית בניגוד ליתר החוקים, המנוסחים בפירוט רב.

בתוכן: חוקי יסוד יעסקו בנושאים של מבנה המשטר והגבלת שלטון, וחוק רגיל באיסור של נושא ספציפי ובעונש הצפוי.

במעמד: שינוי של חוק יסוד משוריין או בחוק שיש בו פסקת הגבלה יעשה רק על ידי רוב מוחלט ואילו שינוי חוק רגיל יעשה ברוב רגיל.

עד היום נחקקו בישראל 12 חוקי יסוד, רובם עוסקים ברשויות השלטון ושניים בזכויות האדם והאזרח.

סוג חוק	צורה	תוכן	מעמד
<u>חוק רגיל</u>	מציינים בכותרת את שנת החקיקה ובתחתית החוק מופיעים בעלי התפקידים המכהנים במועד רישום החוק (נשיא, רה"מ, יו"ר הכנסת והשר הממונה)	עוסק באיסור של נושא ספציפי ובעונש הצפוי	שינוי חוק רגיל יעשה ברוב רגיל
<u>חוק יסוד</u>	לא מציינים את השנה או את בעלי התפקידים	בעניינים שבהם עוסקת חוקה, כמו הגדרת אופייה ודמותה של המדינה, תפקידיהם וסמכויותיהם של רשויות השלטון, הגדרת מבנה המשטר והבטחת זכויות האדם והאזרח	לחלק מחוקי היסוד בדומה לחוקה יש מעמד על שמתבטא ב: א. <u>שריון סעיפים בחוק</u> – ניתן לשנות חוק יסוד רק ברוב מוחלט (מעל 60 חברי כנסת). ב. <u>פסקת הגבלה</u> – מונעת מהרשות המחוקקת לחוקק חוק הסותר את תוכנו של חוק יסוד, אלא אם התקיימו שלושה תנאים – החוק הולם את ערכיה של מדינת ישראל, נחקק לתכלית ראויה, ופגיעתו בעקרונות חוק היסוד היא במידה שאינה עולה על הנדרש. שריון סעיפי החוק מגן על מעמדו הפורמלי ואילו פסקת ההגבלה מגינה על מעמדו במובן המהותי, כי היא עוסקת בהגנה על עקרונות החוק בהתאם לפרשנות שתינתן להם על ידי הרשות המחוקקת ועל ידי הרשות השופטת שמבקרת את החוק.
המשמעות	מעניק לחוק יסוד מעמד על של חוק שאינו מוגבל בזמן	חוקי היסוד כתובים בלשון קצרה ותמציתית בניגוד ליתר החוקים, המנוסחים בפירוט רב	שינוי של חוק יסוד משוריין או בחוק שיש בו פסקת הגבלה יעשה רק על ידי רוב מוחלט

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (1992)

החוק מפרט את זכויות היסוד של האדם בישראל עליהן הוא מגן: הזכות לחיים ושלמות הגוף, הקניין, חרות אישית, חופש תנועה, כבוד ופרטיות. חוק זה לא משוריין, אך יש בו פסקת הגבלה לפיה ניתן לחוקק חוק הסותר את הזכויות שבחוק היסוד רק

בתנאי שהוא הולם את ערכיה של מדינת ישראל, נועד לתכלית ראויה ופגיעתו בזכות מידתית (אינה עולה על הנדרש).

השימוש שעושה בו בית המשפט בבסיס לפסילת חקיקה של הכנסת נתונה במחלוקת ציבורית.

חוק יסוד: חופש העיסוק (1992)

החוק קובע את זכותם של כל אזרח ותושב במדינה לעסוק בכל עיסוק ומקצוע. החוק משוריין כולו – ניתן לשנות אותו רק ע"י חקיקת חוק יסוד חדש ברוב מוחלט. בחוק יש פסקת הגבלה לפיה ניתן לחוקק חוק הסותר את הזכויות שבחוק היסוד רק בתנאי שהוא הולם את ערכיה של מדינת ישראל, נועד לתכלית ראויה ופגיעתו בזכות מידתית (אינה עולה על הנדרש). בחוק יש סעיף התגברות המאפשר לכנסת לחוקק חוק רגיל הסותר חוק יסוד זה לזמן קצוב (4 שנים) גם ללא התקיימות תנאי פסקת ההגבלה, אם החוק התקבל ברוב מוחלט ונאמר בו שהוא תקף על אף האמור בחוק יסוד זה.

השימוש שעושה בו בית המשפט בבסיס לפסילת חקיקה של הכנסת נתונה במחלוקת ציבורית.

חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי (2018)

מטרת חוק היסוד: הגדרה וקביעה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי

- חוק הלאום הינו חוק יסוד, ועל כן יהיה חלק מהחוקה העתידית של מדינת ישראל.
- החוק נחקק כדי לאגד בתוכו את מאפייני מדינת ישראל כמדינה יהודית.
- החוק נותן מעמד על לחלק מהמאפיינים היהודיים של המדינה, שלא היה להם מעמד כזה קודם לכן, למשל: מעמד השפה העברית.
- מטרת החוק היא לבסס את מעמדה של ישראל כמדינת הלאום היהודי.

מאפייניו של חוק הלאום בחוק יסוד

תוכן:

- חוק הלאום מדבר על אופי המדינה ועל מאפייניה. הסעיף הראשון בחוק מדבר על ארץ ישראל כמולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שבה הוקמה מדינת ישראל.
- מדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי, ובה הוא מממש את זכותו להגדרה עצמית.
- מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל הינו ייחודי לעם היהודי - זהו הקשר הייחודי בין העם היהודי לארץ ישראל.

צורה:

- שמו – חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום היהודי.
- אין תאריך בחוק.
- חוק הלאום מנוסח בקיצור ומפנה לחקיקת חוקים אחרים, למשל – מעמד השפה הערבית כמעמד מיוחד המצריך חקיקה.

מעמד:

בחוק הלאום יש פסקת הגבלה:

1. ניתן לשנות את רק באמצעות חוק יסוד אחר (ולא באמצעות חוק רגיל).
2. ניתן לשנות רק באמצעות חוק יסוד שהתקבל בכנסת על-ידי רוב מוחלט (61 חברי כנסת ומעלה).

חוק השבות (1950)

קובע שכל יהודי זכאי לעלות לישראל עם בן זוגו, ילדיו, נכדיו ובני זוגם. עפ"י החוק, יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה, או שנתגייר והוא אינו בן דת אחרת.

חוק השבות קבע את זכותו של כל יהודי לעלות ארצה, למעט חריגים מעטים. זוהי זכות גורפת בכמה היבטים: עליית יהודים אינה מוגבלת למכסות הגירה, אינה מוגבלת מטעמים כלכליים של העולה, או מטעמי יכולת קליטה של המדינה; זכות העלייה היא זכות אישית של היהודי העולה, ולא רק זכותה של המדינה לקלוט אותו. בדרך כלל אשרת עולה ניתנת לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל, בין אם עשה זאת לפני הגיעו לארץ ובין אם לאחר מכן. הזכות לעלות לא תינתן ליהודים שפעלו נגד העם היהודי, שעלולים לסכן את בריאות הציבור או בטחון המדינה, או בעלי עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור.

חוק זה נובע מתפיסת מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ולכן מקובל לראות בו חוק מבחין ולא חוק מפלה. במדינות רבות בעולם קיימת מדיניות הגירה המבוססת על עקרון שבות של בני הלאום.

שאלת השוויון: סוגיית העדפת היהודים בחוק השבות

לב הוויכוח הוא השאלה, האם העדיפות בחוק השבות ליהודים בנוגע לעלייה הנה בגדר אבחנה מותרת או אפליה פסולה.

הנימוקים התומכים בעמדה שמדובר חוק "מבחין"

1. רוב אזרחיה היהודים של מדינת ישראל רואים במדינת ישראל מדינה יהודית-ציונית כלומר, מדינת העם היהודי שרוב אזרחיה יהודים ואת חוק השבות כאמצעי לממש מטרה זו.
2. חלק מהזכות להגדרה עצמית היא שלכל מדינת לאום זכות לקבוע את אופי אוכלוסייתה ולשמור על היתרון הכמותי של הרוב הלאומי עמו מזוהה המדינה, וחוק השבות מסייע לכך.

הנימוקים התומכים בעמדה שמדובר בחוק "מפלה"

1. מיעוט יהודי קטן ורוב ערביי ישראלי גדול גורסים כי ישראל היא בראש ובראשונה מדינה דמוקרטית המחויבת למימוש השוויון לכלל אזרחיה בהתעלם מההבדלים הדתיים והלאומיים ביניהם
2. חוק השבות הוא חוק מפלה שכן הוא מקנה עדיפות ליהודים בכל הנוגע לעלייה לארץ, מנימוקים בלתי רלבנטיים כגון דת, לאום ומוצא, ולכן יש לבטלו ולחוקק במקומו חוק שיקבע תנאי הגירה והתאזרחות כמקובל בכל מדינה דמוקרטית

חוק האזרחות (1952)

שיטות המקובלות בעולם לרכישת אזרחות: דין הקרקע ודין הדם

1. דין הקרקע:

כלומר שהאזרחות נרכשת באמצעות לידה בטרטוריה של המדינה ללא קשר לאזרחות ההורים.

2. דין הדם:

כלומר האזרחות עוברת בירושה מההורים לבניהם ללא קשר למקום הלידה

רוב המדינות משלבות בין השתיים ישראל מעדיפה את דין הדם

הדרכים לקבלת אזרחות על פי החוק

חוק האזרחות משנת קובע שבע דרכים לרכישת אזרחות ישראלית

1. **מכוח שבות:** החוק קובע כי זכאי חוק השבות זכאים גם לאזרחות. כל מי שחל עליו חוק השבות, כלומר יהודים ובני משפחתם העולים לארץ, מקבלים מיידית ואוטומטית אזרחות ישראלית.
2. **מכוח ישיבה בארץ:** תושבים שחיו בישראל עם קום המדינה זכאים לאזרחות. קביעה זו מתייחסת הן למי שנולדו לתושבים יהודים והן למי שנולדו לתושבים שאינם יהודים.
3. **מכוח לידה:** החוק מבחין בין מי שנולדו בארץ לבין מי שנולדו מחוץ לארץ –
 - א. מי שנולד בישראל לאב או לאם שהם אזרחים ישראלים - יהיה אזרחי ישראלי
 - ב. מי שנולד מחוץ לישראל זכאי לאזרחות ישראלית, אם אביו או אמו היו אזרחים ישראליים מכוח שבות או ישיבה בישראל או התאזרחות או לידה בישראל או אימוץ.
4. **מכוח לידה וישיבה בישראל:** בחוק נקבעה זכאות לאזרחות גם לתושבי ישראל שנולדו לאחר קום המדינה ולא הייתה להם מעולם שום אזרחות (לא יהודים). זאת, בתנאי שהיו תושבים חמש שנים רצופות ובתנאי שהגישו בקשה לקבלת אזרחות ישראלית בתקופה שבין יום ההולדת ה-81 לבין יום ההולדת ה-12 שלהם. הזכאות הזו אינה מוחלטת, והיא טעונה אישור של שר הפנים. די שאחד ההורים יהיה אזרח או תושב, כדי שילדו יקבל אזרחות מכוח לידה.
5. **מכוח אימוץ:** קטין שאינו אזרח ישראלי ושאומוץ על ידי הורים שהם אזרחי ישראל.
6. **מכוח התאזרחות:** אדם שאינו אזרח ומבקש להתאזרח צריך לעמוד בתנאים הבאים:
 - א. הוא נמצא בארץ
 - ב. היה בישראל במשך שלוש שנים מתוך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה
 - ג. זכאי לתושבות קבע
 - ד. השתקע בארץ או שיש לו כוונה להשתקע בארץ
 - ה. יודע את השפה העברית
 - ו. ויתר על אזרחות קודמת, או הוכיח שיוותר עליה כשיקבל אזרחות ישראלית
7. **מכוח הענקה:** מכוח הענקה. שר הפנים רשאי להעניק אזרחות ישראלית לקטין על פי בקשת הוריו, וכן לתושב ישראל הנמצא בישראל, אם השר שוכנע כי הוא מזדהה עם מדינת ישראל ויעדיה, וכן אם הוא או בן משפחתו שירתו שירות פעיל בצבא או פעלו פעולה של ממש לקידום ענייני המדינה. בנוסף, במקרה של קשר נישואין בין אזרח ישראלי לבן זוג זר (שאינו אזרח ישראלי ואינו יהודי) רשאי שר הפנים להעניק אזרחות לבן זוג הזר על פי שיקול דעתו.

מגילת העצמאות

מגילת העצמאות אינה חוקה והיא אף אינה חוק מחייב. מיד עם קום המדינה דחה בית המשפט העליון טענות של עותרים, אשר ביקשו לראות במגילת העצמאות כשלעצמה חוקה פורמלית. ואולם, עם השנים נקבע כי היא מהווה מסמך בעל חשיבות ערכית ומשפטית, המבטא את חזון המדינה ואת עיקרי אמונתו של העם. ככזו משמשת לא אחת רוחה של מגילת העצמאות בסיס לפעילותן של הרשויות השונות ולהנחייתן לנהוג באופן שוויוני, וככלי פרשני בידי בתי המשפט.

קיימת הסכמה רחבה על חשיבותה של הכרזת העצמאות כיסוד חוקתי מהנימוקים הבאים:

- ההכרזה קובעת את עקרונות היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
- ההכרזה מנחה את רשויות השלטון בפעולתן

כאמור, ההכרזה אינה חוקה ואינה חוק, אך היא מסמך הצהרתי המנחה את רשויות השלטון בפעולתן, וכלי עזר פרשני שחובה על בתי המשפט ושאר הרשויות לפעול לאור עקרונותיו בבואם לפרש את החקיקה, שמכוחה הם פועלים.

דוגמאות לכך שהכרזת העצמאות היא יסוד חוקתי עליון שהשופטים מתבססים עליהם בפסיקתם:

- **בג"צ קול העם (1953):** בעתירה זו דון צו של שר הפנים, אשר הורה לסגור שני עיתונים – "קול העם" ו"אל-איתיחאד" – על רקע ביקורת חריפה שהתפרסמה בהם נגד צה"ל ומדיניות הממשלה.
- העותרים טענו לפגיעה בחופש הביטוי, ובפסק הדין, שביטל את סגירת העיתונים, הסתמך השופט אגרנט על מגילת העצמאות.
- **בג"צ שקדיאל:** בג"צ קיבל את עתירתה של גב' שקדיאל כנגד שר הדתות שפסל את מועמדותה לחברות במועצה הדתית בשל היותה אישה, שכן בחוקי שירות הדת היהודיים אין התייחסות למקרה כזה ולכן יש לפרשו לפי עקרון השוויון בהכרזה "ללא הבדל דת גזע ומין".

עם זאת, על אף המעמד החשוב שייחס בית המשפט לערכים הנלמדים ממגילת העצמאות, בית המשפט רואה את חוקי הכנסת כעליונים.

דוגמה לכך: **בג"צ רוגוז'ינסקי:** בג"צ דחה בקשה של בני זוג יהודים שסירבו להינשא על פי חוק שיפוט בתי הדין הרבניים. בקשתם התבססה על הזכות לחופש מדת וחופש המצפון המעוגנים בהכרזת העצמאות. בג"צ דחה את בקשתם, מכיוון שמדובר בחוק מפורש וחד משמעי (בתי דין רבניים) שאינו מאפשר נישואים שאינם דתיים. במקרים שבהם קיים חוק מפורש, פועלת הרשות השופטת על פי החוק, גם אם הוא סותר את העקרונות שבהכרזה.

לכן, במצבים שבהם מתנגש ערך המוזכר במגילת העצמאות עם חוק מפורש - החוק המפורש גובר. ערכי היסוד שבמגילת העצמאות משמשים לעיתים את בית המשפט על מנת לבטל החלטות של שרים או של פקידים ברשות המבצעת, אך לא לביטול חוקים של הרשות המחוקקת.

מעמדה של ההכרזה התחזק בשנת 1992 עם חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, הקובעים כי הזכויות המעוגנות בהם יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה, ולכן הכנסת מוגבלת בחקיקת חוקים הפוגעים בעקרונותיה.

ההכרזה מנחה את שלוש רשויות השלטון :

- א. הכנסת: העקרונות והערכים של המדינה כיהודית ודמוקרטית מתבטאים בחקיקה בכנסת. למשל עקרון השוויון " יתקיים שוויון חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין". מתבטא בחוק שוויון זכויות האישה, תש"א 1951.
- ב. הממשלה: בפעולתה כרשות מבצעת ודורשת ממנה לדוגמא לפעול בדרך שוויונית כלפי אזרחים ולהימנע מאפלייתם.
- ג. בתי המשפט: כאשר אין חוק ברור של הכנסת, או כאשר אפשר לפרש את החוק באופנים שונים, יעדיף בית המשפט את הפירוש המתיישב עם העקרונות שנקבעו בהכרזה.

המהפכה החוקתית

כאשר מדברים על "מהפכה חוקתית", המשמעות היא שמדינת ישראל הופכת מדמוקרטיה פרלמנטרית, שבה לחוקי הפרלמנט יש עליונות, לדמוקרטיה חוקתית בעלת חוקה פורמלית חלקית, שבה קיימת לרשות השופטת סמכות לבטל חוקים, הנראים בעיניה כסותרים ערכים חוקתיים שמעוגנים בחוקי יסוד. כלומר, בית המשפט ניצב מעל בית הנבחרים, ויכול לבטל חוקים שהכנסת חוקקה.

דמוקרטיה חוקתית: נבדלת מדמוקרטיה פרלמנטרית בעיקר בשאלת ריבונות העם: בדמוקרטיה פרלמנטרית ריבונות העם משתקפת בפרלמנט, שהוא הרשות העליונה כנבחר הציבור. בדמוקרטיה חוקתית, לעומת זאת, ריבונות העם משתקפת בחוקה שקיבל העם ומגבילה את החלטות הפרלמנט. בית המשפט (אף כי אינו נבחר ציבור) נתפס כמגן על רצון העם בעת שהוא פוסל חוקים, אם לפי פרשנותו הם מנוגדים לחוקה.

ב-1992 נחקקו שני חוקי היסוד המגינים על זכויות אדם: ח"י כבוד האדם וחירותו, וח"י חופש העיסוק.

בפס"ד בנק המזרחי (1995) קבע בית המשפט כי בסמכותו לקבוע האם חוק מסוים שחוקקה הכנסת פוגע בזכויות אדם ולפיכך בטל, שכן הוא מחשיב את אותם חוקי היסוד כבעלי מעמד חוקתי (מעמד על ביחס לחוקים רגילים). לאור זאת נפסלו מאז כ- 15 חוקים שנחקקו בכנסת. לאחר חקיקת 2 חוקי היסוד, בג"צ החל לנקוט בגישה שיפוטית אקטיבית יותר.

המהפכה החוקתית, והאופן שבו היא התרחשה עוררו מחלוקת ציבורית וערכית, שנמשכת עד היום.

הטיעונים בעד המהפכה החוקתית:

- **הכנסת היא שיצרה את המהפכה החוקתית, והיא מוסמכת לכך:**
הכנסת היא רשות מכוננת (מחוקקת חוקה), והיא מממשת את סמכותה כרשות כזו כשהיא מחוקקת חוקי יסוד.
- **לא בית המשפט מבטל את חוקי הכנסת, אלא חוקי היסוד:**
מקור הסמכות של בית המשפט לבטל חוקים שהכנסת מחוקקת נובע מחוקי היסוד (שהכנסת חוקקה), שגוברים על החקיקה הרגילה, ולא מהכרעתו של בית המשפט.
- **חוקי היסוד שמגינים על זכויות אדם (כבוד האדם וחירותו, חופש העיסוק) מממשים ומבטאים את המחויבות המוסרית של מדינת ישראל לזכויות האדם:**
חוקים אלה מאפשרים הגנה על זכויות אדם, גם מפני מחוקק שינסה לפגוע בהן, והמהפכה החוקתית ממשיכה מסורת של בתי משפט בהגנה על זכויות אלה.
- **מרבית מדינות העולם אימצו בחוקה שלהן את סמכות בית המשפט לבטל חוקים**

- **כוונת המחוקק:**

חלק מחברי הכנסת שתמכו חוקי היסוד טענו מאוחר יותר שלא התכוונו לכונן חוקה, אך טענה זו אינה רלוונטית, שכן תפקידו של שופט היא לפרש את החוק ולא את הכוונה האישית של המחוקק.

הטיעונים נגד המהפכה החוקתית:

- **העם לא הסמיך את הכנסת לחוקק חוקה:**

הכנסת הראשונה נבחרה, בהתאם למגילת העצמאות, כאספה מכוננת שתכתוב חוקה, אך מאז שהפכה לרשות מחוקקת בשנת 1949, האזרחים יודעים שהם בוחרים רשות מחוקקת ולא אספה מכוננת. כלומר, אילו האזרחים היו יודעים שהם בוחרים אספה מכוננת, ייתכן ואופן הצבעתם היה משתנה.

- **הכנסת לא התכוונה לכונן ולאמץ חוקה:**

חוקות במדינות בעולם מתקבלות ברגעים מכוננים בחיי אומה (כמו בהתכנסות ציבורית רחבה אחרי הכרזת עצמאות), או לאחר דיון ציבורי ארוך ומקיף (כפי שהיה בקנדה). כלומר, החוקות במדינות הדמוקרטיות התקבלו בתהליך שיש בו מודעות מלאה לכך שמכוננים חוקה.

לעומת זאת, חוקי היסוד שנחקקו בשנת 1992 עברו ללא דיון ציבורי משמעותי ובנוכחות מצומצמת של חברי כנסת.

- **בית המשפט יצר את החוקה, אך הוא אינו מוסמך לכך ולא ראוי שיהיה מוסמך לכך:**

המהפכה החוקתית לא התרחשה עם חקיקתם של חוקי היסוד בשנת 1992, אלא רק עם נתינת פסק הדין ("המזרחי" - 1995), שבו בית המשפט פירש את חוקי היסוד כ"חוקתיים". זהו תקדים, ואין דומה לו בעולם, לכך שמתברר בעת פסק דין מאוחר, שקיימת בכלל חוקה. כלומר, החוקה היא יצירה של בית המשפט ולא של הציבור או נבחר הציבור. בנוסף, העובדה שבית המשפט ממשיך לחדש זכויות חוקתיות נוספות באמצעות פרשנויות חדשות, גם למעלה מ-20 שנים לאחר חקיקת חוקי היסוד, רק מחדדת את הקביעה שאת החוקה בישראל יצר וממשיך ליצור בית המשפט.

אך, בית המשפט מעולם לא הוסמך לכונן חוקה וגם לא ראוי שיוסמך לכך, כיוון שאיננו נבחר ציבור. אל מול הטענה שהחוקה היא זו שעומדת מעל לנבחר הציבור, טוענים המבקרים כי אם בית המשפט הוא זה שקובע למעשה את החוקה, הרי שלא מדובר בשלטון החוקה אלא בשלטון המשפטים. בהמשך לכך נטען, כי אף לשיטתו של מי שרואה בדמוקרטיה חוקתית מודל ראוי, הדבר מותנה בחוקה מפורשת. מצב שבו בית המשפט הוא המכריז על החוקה, פוגע בעיקרון הדמוקרטי של הפרדת רשויות.